

代持型受贿罪认定标准及裁判路径

——徐某某受贿案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市高级人民法院(2022)渝刑终125号刑事裁定书

2. 案由：受贿罪

【基本案情】

2012年至2013年，徐某某利用担任某银行私人银行部副总经理(分管投资)职务上的便利，接受某公司法定代表人李某某(另案处理)的请托，通过签批基金项目推荐函、向相关人员打招呼等方式，为某公司设立的“A”“B”基金获得工行资金投入，以及某公司成为某银行总行、浙江分行、深圳分行、重庆分行、北京分行股权母基金管理人提供帮助。2013年至2019年，某公司工行类业务收入共计2亿余元。2016年，徐某某先后收受李某某给予的某公司20%股份(评估价值21490万元)、房产一套(价值2832.354491万元)，折合共计24322.354491万元等犯罪事实。具体事实如下：

2016年6月，李某某向徐某某提出给予某公司20%股份。徐某某同意，但表示其在职期间不便直接持有。后二人商议将该股份继续登记在李某某名下，

由李某某代徐某某持有，待方便时再行处理。2016年7月，李某某再次向徐某某表示送予某公司20%股份，徐某某提出待其女儿徐某1大学毕业后择机将股份转给徐某1，李某某同意。经评估，某公司20%股份在2016年6月30日价值21490万元。2019年1月、9月，某公司进行了2017年度、2018年度股东分红，李某某将某公司20%股份应分红1040万元(税后)的情况告知徐某某，徐某某与李某某商议后决定分红款由李某某代持，待时机合适再行处理。分红款打到李某某账户上后，李某某将分红款用于购买稳健、可及时赎回的理财产品，并将此事告知徐某某，徐某某表示同意。

2016年8月，被告人徐某某收受李某某所送位于某小区××号××室房产一套。该房产系李某某以投资中心名义购买，并根据徐某某要求安排人员对房屋楼顶加建阳光房。2016年至2019年，投资中心为该套房产支付购房款、税费等费用共计2832.354491万元。2019年年初，徐某某为掩人耳目，授意李某某及其家人入住该房屋。李某某便安排其在上海看病的父亲在该房屋内居住十余天。

【案件焦点】

1. 行受贿双方就送股权及分红款达成合意，但该股权及分红款始终在行贿人名下，实为行贿人占有和控制，是否认定受贿未遂；2. 受贿人没有实际使用该房屋，但不影响其能够通过其关联人对该房屋控制和使用，是否能够认定受贿人对该房产有足够的控制力，是否属于受贿既遂。

【法院裁判要旨】

重庆第五中级人民法院经审理认为：徐某某利用职务之便，为李某某等人已提供实际帮助，对受贿款物的金额、处理方式双方已达成合意，已经着手实施犯罪，由于徐某某被查处等原因受贿款物未实际交付，故应认定其犯罪未遂。关于房产，徐某某授意李某某在屋顶加装阳光房、安排李某某将门禁卡交给王某、为了逃避调查而多次要求李某某入住，但却反对李某某将房屋用于公司办公等行为，反映徐某某积极实施收受房屋并进行支配和处置，可以认定徐某某

对该房产有足够的控制力，故应认定其受贿既遂。徐某某收受的某公司股权系具有价值的实质性财物，而非仅仅收受股份对应的分红款，故应当以股权价值认定其受贿金额。采用市场法得出的股权价值与本案其他证据相互印证，该评估意见程序合法、方法适当、结论正确，应予采信。

综上，根据徐某某受贿数额特别巨大，使国家和人民利益遭受特别重大损失等犯罪情节，结合其上述从轻处罚情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第三项、第二款、第三款，第二十三条，第五十九条，第六十四条，第五十四条，第五十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，第四条第一款、第二款，第十五条，第十八条之规定，判决如下：

一、被告人徐某某犯受贿罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、对被告人徐某某受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。

一审宣判后，徐某某提出上诉。

重庆市高级人民法院经审理认为：上诉人徐某某利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的房产、公司股份、资金等财物折合人民币共计25502.612538万元，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。徐某某的行为使国家和人民利益遭受特别重大损失，依法应予严惩。徐某某收受的上述财物中，有22574.768047万元并未实际获取或支配，系受贿未遂，可从轻处罚。徐某某如实供述组织掌握的大部分受贿犯罪事实，主动交代组织未掌握的小部分受贿犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。

综上，本案事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，重庆市人民检察院出庭意见成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，行受贿双方约定由行贿人、关系人代持房产、股权、货币(分红款)等财物的受贿形式，是实践中非常典型的代持型受贿犯罪案例。职务犯罪特别是受贿罪的犯罪形态，在当前办理职务犯罪中存在争议。传统观点认为，只有受贿人实际收到财物，才是受贿罪既遂。但随着受贿手段的不断翻新和行受贿双方反侦察意识的不断增强，实际收到财物说在司法实践中日趋呈现出诸多局限：一是形式上收受财物并不一定意味着发生了危害后果；二是收受财物并不一定意味着受贿罪已经达到既遂状态；三是没有取得财物并不代表不成立受贿既遂。经梳理裁判文书网公布的已生效裁判文书的观点，其各自认定贿赂犯罪的犯罪形态也存在着裁判说理标准不一的问题。本案作为双方约定代持型受贿罪的判例，既要认定代持房产，代持股权、货币(分红款)的犯罪形态，还涉及轻资产公司股权的价值认定以及对代持房产掌控力的具体判断方法等复杂问题。生效裁判对该案所涉代持财物型受贿犯罪的犯罪形态以及犯罪金额的认定标准逐项做了析法说理，对司法实践中审理该类案件提供了裁判路径的借鉴。

一、关于受贿罪犯罪形态裁判观点梳理

收受财物的把握直接影响既未遂。对“收受财物”实质的理解有以下观点：一是转移说，以财物是否离开所有权人为标准；二是隐匿说，以财物是否被隐藏为标准；三是失控说，以财物是否脱离所有权人控制为标准；四是控制说，以财物是否被受贿人实际控制为标准。笔者赞同控制说的观点，受贿罪的既遂标准是收受财物，收受财物的本质是实际控制财物，控制说更准确地揭示了收受财物的实质。

实践中，有以下几种具有代表性的犯罪形态裁判观点：第一，认定构成犯罪既遂主要有以下几种观点：一是占有改定，视为已经交付。该观点体现了“约定”本身就是受贿罪的一种表现形式，而且达成协议就构成受贿既遂的观点；二是利用职权为行贿人谋取了利益的。该观点认为受贿人利用职权为行贿人谋取了利益，故构成既遂犯罪，如果说占有改定、观念交付是对有损职务廉洁行为在刑法意义上的约定惩处，那么该观点则要求需要具体实施为行贿人谋

取利益的事实支撑；三是已经既遂，不存在未遂。该观点主要针对已经收受财物后的后续处置行为，认为行受贿双方已经完成权钱交易构成既遂犯罪后，无未遂存在的余地。第二，认定构成犯罪未遂主要有以下几种观点：一是约定的钱款尚未给付。该观点认为双方约定的行贿款尚未给付，权钱交易尚未完成，故构成未遂犯罪；二是约定代持的财物尚未给付。该观点认为受贿人未实际接受财物、入住房屋等情形，构成未遂犯罪。正如储槐植教授所言，刑法实际上是一门经验科学，在研究方法上更多依赖的是社会经验法则，而不是抽象的理性思辨。^①

二、认定代持型受贿罪既、未遂犯罪形态标准

实践中因个案情节不同，对犯罪形态结论而言，有以下观点：一是约定代持的财物尚未支付、尚未完全支付的，未遂。该观点认为，行受贿双方虽对行贿的财物进行了约定，但因行贿人代持的财物尚未给付或完全给付，应以犯罪未遂定罪处罚；二是代持财物的，既遂。该观点的说理较之